

1509442-19.2021.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HEITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do tipo, temos: "O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília-SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1509442-19.2021.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509442-19.2021.8.26.0344

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS JOSÉ RODRIGUES

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. HEITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

Vistos.

LUCAS JOSÉ RODRIGUES, foi denunciado e está sendo processado como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei nº 10.826/03, todos c.c. art. 61, II, "j" do Código Penal, na forma do art. 69, porque, supostamente, no dia 29 de setembro de 2021, por volta das 17h, na Rua Ângelo Trevelin nº 52, Jardim Teotônio Vilela, nesta cidade e comarca de Marília, o réu (i) guardava e tinha em depósito para fins de disseminação 750 (setecentos e cinquenta) porções individualizadas e 01 a granel contendo 480,26g de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ademais, consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu (ii) possuía munições de uso permitido, consistentes em 12 munições, calibre 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por fim, se extrai da denúncia que em momentos anteriores e concomitantes aos fatos acima citados, o réu (iii) associou-se a terceiros ainda não identificados, para o fim de praticar, não reiteradamente, o crime de tráfico de entorpecentes.

Auto de prisão em flagrante e apuração dos fatos às fls. 04/139, sendo que houve conversão em prisão preventiva às fls. 58/62.

A Decisão de fls. 171/175 recebeu a denúncia e determinou a citação do réu. Citado (fl. 197) o réu apresentou resposta escrita à acusação às fls. 192/195. Realizada audiência de instrução foram colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação, de defesa e, ao final, realizado o interrogatório do réu. Encerrada a instrução, o Parquet reiterou o pleito condenatório, aduzindo que a materialidade e autoria restaram comprovadas, sendo que o tráfico de drogas está devidamente comprovado, eis que o acusado foi detido enquanto guardava e tinha em depósito grande quantidade de entorpecentes. Do mesmo modo, a associação para o tráfico resta inequívoca, ante as condições do crime, principalmente diante da patente divisão de tarefas para a mercancia ilícita, ao passo que o réu era o responsável pela preparação e embalagem das drogas, enquanto seus associados promoviam a aquisição e posterior comercialização. Em relação à fixação da pena, o parquet pugna pela não aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em razão da quantidade de drogas apreendidas.

A defesa, por sua vez, em memoriais finais escritos (fls. 246/270) arguiu fragilidade probatória em relação ao crime de associação criminosa, pedindo a absolvição do acusado. Em caso de condenação, pugnou pela fixação de penas mínimas, em regime inicial aberto, tal como a aplicação do princípio da insignificância em relação ao delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face do réu, que supostamente teria cometido os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, e porte de munição de uso permitido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

Com efeito, a materialidade está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 04/12, boletim de ocorrência de fls. 13/15, auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, fotos de fls. 18/21, laudo de constatação de fls. 23/24, pelo laudo químico toxicológico de nº 329.477/2021 de fls. 98/102, laudo nº 327.802/2021 de fls. 105/114, que constatou a eficácia das munições, bem como pelas demais provas carreadas aos autos.

Ademais, a autoria é certa e recai sob o réu.

A testemunha LEONARDO ANDRÉ MARTINS PAES, policial militar, quando ouvida em juízo, relatou que: estavam em patrulhamento pela zona sul da cidade, quando avistaram dois rapazes em uma calçada, sendo que um estava de moto e outro a pé; que quando o réu percebeu a aproximação da viatura dispensou um cigarro no chão, momento em que os policiais decidiram realizar a abordagem; realizada a busca pessoal nos indivíduos, nada de ilícito fora encontrado; que perguntou para o que estava a pé o que seria o cigarro, o réu disse que era usuário de maconha, sendo negado quando perguntado se fazia uso de outras substâncias. Narra que questionou o réu se haveria mais cigarros de maconha dentro de sua residência, tendo o réu respondido que teria mais em seu quarto; que questionou o réu se poderia fazer a verificação desses cigarros, o que o réu autorizou a entrada dos policiais na residência.

Discorre que em verificação no quarto do réu, em cima de uma cômoda havia alguns pinos de cocaína; que questionou o réu se este era usuário de cocaína, o réu disse que sim; que os pinos estavam todos novos; que seu auxiliar na revista acabou encontrando uma sacola com uma substância que aparentava ser cocaína, além de alguns eppendorfs, uns vazios e outros cheios, além de munições de calibre 22; que perguntou para o motociclista qual o motivo de estar na residência do réu, se ele teria ido comprar algum entorpecente do réu, este negou, alegando que somente fora cobrar uma dívida de venda de roupa que o réu lhe devia; que não conseguiu apreender o cigarro que o réu dispensou antes da abordagem; que o réu não era conhecido nos meios policiais. Questionado se o réu estaria associado com outras pessoas para praticar o tráfico de entorpecentes, narra que: questionou a posse da cocaína encontrada, uma vez que o réu teria dito aos policiais que não fazia o uso desse entorpecente, o réu teria dito que recebeu um dinheiro para fracionar a droga, porém não disse de quem seria os tóxicos.

A testemunha ELTON SALES, policial militar, quando ouvida em juízo, relatou que:

estavam em patrulhamento pela zona sul da cidade, quando avistaram dois rapazes uma calçada, um como uma moto próxima e o réu estava a pé; que quando o réu percebeu a aproximação da viatura dispensou um cigarro em uma poça de água que tinha próximo ao meio-fio; realizada a busca pessoal no réu, nada de ilícito fora encontrado; que o réu afirmou que o cigarro que dispensara era de maconha; que perguntou para o réu se teria mais algum entorpecente, o réu respondeu que teria mais cigarros de maconha na residência; que questionou o réu se poderia fazer a verificação desses entorpecentes, o que o réu autorizou a entrada dos policiais na residência.

Discorre que em verificação no quarto do réu, em cima de uma cômoda havia alguns pinos de cocaína; que questionou o réu sobre os pinos encontrados, sendo que nesse momento o réu aparentava nervosismo e não respondeu mais nada aos policiais. Prosseguindo com a vistoria, a testemunha narra que encontrou, debaixo da cama localizou uma sacola com cocaína, sendo uma porção grande, tipo a granel, além de alguns pinos; que em cima da cama do réu tinha uma pochete preta e que em verificação, acabou encontrando as munições; que questionou o réu sobre os entorpecentes, sendo que o réu teria dito aos policiais que estava sendo pago para fracionar e embalar a droga em troca de R\$ 500,00 (quinhentos reais); que o réu não disse quem seria o proprietário das drogas; que os pinos que estavam sob a cômoda estavam limpos; que não conhecia o réu nos meios policiais.

A testemunha GUILHERME FERREIRA SILVA, quando de seu depoimento em juízo, sobre os fatos disse que: estava conversando com o réu no lado de fora de sua casa, sendo que antes da polícia realizar a abordagem o réu estava preparando um cigarro de maconha; que ambos eram usuário de maconha, sendo que o cigarro era para uso de ambos; que a propriedade do cigarro era do réu; que quando os policiais realizaram a abordagem perguntaram se poderiam entrar na residência, sendo que Lucas autorizou; que ficou aguardando do lado de fora o término da abordagem; que após os policiais o chamaram para dentro da residência e lhe mostrou os entorpecentes; que não se recorda se os policiais indagaram o réu sobre o cigarro de maconha, tal como não se recorda se os policiais questionaram sobre mais entorpecentes na residência; que não sabia que o réu se envolvia com drogas; que o réu trabalhava como cabeleireiro; que saiba, o réu somente consumia maconha, sendo que já utilizou junto com o réu; que não tem conhecimento que o réu vendia entorpecentes.

A testemunha de defesa IVETE CRISTINA DE SEIXAS ANDRADE, quando ouvida em juízo, relatou que: conhece o réu, uma vez que era amiga de uma tia dele; que o réu e a família frequenta a igreja das testemunhas de Jeová, sendo que todos da família são muito religiosos; que na época dos fatos o réu trabalhava como cabeleireiro, sendo que já teve seu próprio salão; que saiba, o réu não teve passagem pela polícia; que não tem conhecimento que o réu se associava com outras pessoas para fins de traficância; que não tem conhecimento de que o réu realizava o tráfico de drogas.

A testemunha de defesa CILENE DA SILVA SANTOS MORIJO, quando ouvida em juízo, relatou que: conhece o réu desde quando ele nasceu, sendo que é amiga de sua avó; que a família do réu é bastante religiosa, sendo que já viu inúmeras vezes o réu saindo da igreja, as diversas fotos que o réu e sua avó lhe mostrava das pregações religiosas; que o réu nunca foi preso, sendo que ele nunca fez nada de errado; que o réu nunca se associou com outras pessoas para o tráfico, sendo que o réu tem amizade com seus filhos, inclusive com sua filha que é policial militar; que o réu sempre trabalhou como cabeleireiro; que o réu tinha um salão, mas depois que não conseguiu pagar o aluguel, começou a cortar cabelo à domicílio; que o réu tem um coração bom, sendo que mesmo que o cliente não tivesse dinheiro, ele realizava o corte mesmo assim.

O réu, LUCAS JOSÉ RODRIGUES, quando interrogado em juízo, disse que as acusações não são verdadeiras. Contudo, relatou que estava devendo um dinheiro para uma pessoa, e essa pessoa tinha uma "biqueira"; que essa pessoa passou a lhe cobrar o dinheiro, mas não conseguia pagar; que um dia pegaram e lhe bateram, pedindo para guardar essa sacola, o que o fez; que recebeu a sacola dois dias antes de ser preso; que só se dispôs a guardar a sacola porque foi ameaçado de morte, e também à sua família; que não sabia o que tinha dentro da sacola, por isso autorizou a entrada dos policiais em sua residência; que os policiais encontraram uns pinos de cocaína, tudo embaixo da cama; que os pinos que estavam na cômoda era de um primo

seu; que na cômoda eram apenas dois pinos, um vazio e um cheio; que somente dentro da sacola havia bastante pinos; que é usuário de maconha; que autorizou a entrada dos policiais na residência, sendo que eles entraram junto com o réu; que já usou cocaína; e que tem certeza que as munições estavam dentro da sacola, uma vez que nunca mexeu com armas.

Pois bem.

Como se observa das provas colhida dos autos, o réu não admitiu expressamente a prática do delito de tráfico de drogas, apresentando uma versão exculpatória de que fora obrigado a guardar os entorpecentes, não tendo conhecimento de que se tratava de drogas.

Ora, mesmo considerando essa versão fantasiosa como verdadeira, tenho que não se exime de culpa a conduta do réu. De fato, não se pode ignorar a quantidade de entorpecente apreendido e os materiais para a sua disseminação, sendo que os utensílios e aparatos apreendidos causam grande lesividade na comunidade e auxiliam em reiterada prática de delito.

De mais a mais, ainda que o réu seja usuário de entorpecentes, o que não se duvida que seja, isso não descaracteriza o crime.

Nesse sentido:

"O traficante pode também ser viciado e, concomitantemente, guardar ou trazer consigo para uso próprio e para a disseminação do vício; por outro lado, o viciado também pode ser instrumento de difusão do mal, quando fornece a droga a outrem. Em ambas as hipóteses acima referidas, prevalecerá o delito mais grave, ficando absorvido o delito do artigo agora comentado. Tanto no caso de um traficante que traz consigo a droga para uso próprio como no caso de alguém que, trazendo originalmente para uso próprio, vem a desviar essa destinação fornecendo-a a outrem, o bem jurídico atingido é a saúde pública em sua forma substancialmente mais grave, não podendo o que dissemina o vício beneficiar-se arguindo sua condição de usuário da droga ("Tóxicos Prevenção Repressão", Vicente Grecco Filho, Saraiva, 7ª edição p. 119)."

Ora, ainda que seja o acusado dependente químico, a circunstância não descaracteriza o crime.

Não é outro o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

A propósito, ressalte-se que para a caracterização do crime de tráfico de drogas não é necessário que tenha sido flagrado em ato de venda.

Nesse sentido:

"Para a configuração do delito não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, transporte, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, fazendo-se, também, inexigível, a tradição, para a consumação (TJSP, Ap. Crim. 899.394/0, 6ª Câ., rel. Des. Marco Antônio, j. 25/10/2007)."

E ainda:

"O crime de tráfico não se consuma apenas com o fato do agente trazer consigo o entorpecente, pois o tipo penal traz diversas figuras típicas, dentre as quais o depósito da droga, o que fica caracterizado na hipótese de o réu ter enterrado na sua residência a substância em local cercado por grades e, portanto, de difícil acesso a estranhos, não restando demonstrada a alegação de que a droga não era sua, ou que não tinha conhecimento da mesma (TJRS, Ap. 699.232.609, 3º Câ., j. 30-9-1999, rel. Des. Saulo Brum Leal, RT 777/688)."

Ademais, conforme previsto no art. 33, caput, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito, nas modalidades de "trazer consigo" e "guardar" entorpecente para fins de tráfico.

Trata-se de tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, também conhecido como tipo alternativo misto, em que as condutas de trazer consigo, guardar, transportar etc. não exigem especial fim de agir.

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do tipo, temos: "O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap. 697.020.717, Câmb., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633).

Em suma, por tudo que se disse acima, não há que se falar em desclassificação do crime imputado na inicial acusatória (artigo 33, da Lei nº 11.343/06) para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/06).

À vista da prova colhida nos autos, portanto, fica indene de dúvidas que o réu, de fato, mantinha em depósito considerável quantidade de substâncias entorpecentes, o que conduz à conclusão irrefutável de que se dedicava à traficância de drogas.

Em relação ao crime de posse de munição de uso permitido, este resta caracterizado, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

Isso porque o bem jurídico tutelado é a coletividade e o crime é de perigo abstrato, bastando somente o armazenamento de munição para gerar um grande perigo à sociedade. Nesse sentido, tem o julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM MANIFESTO CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DE TRIBUNAL SUPERIOR. PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, DESACOMPANHADA DA ARMA DE FOGO. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em cerceamento de defesa quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao parágrafo 1º-A do artigo 557 do Código de Processo Civil, que franqueia ao relator a possibilidade de dar provimento ao recurso especial quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com jurisprudência dominante de Tribunal Superior. 2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o crime de porte ilegal de munição, ainda que desacompanhado da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1442152/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 21/08/2014)"

"HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUCTA. ORDEM DENEGADA. 1. O tipo penal do art. 14, da Lei nº 10.826/03, ao prever as condutas de portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de portar ilegalmente a munição. 2. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes. Precedentes. 3. Ordem denegada. (HC 119154, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 10-12-2013 PUBLIC 11-12-2013)" [grifou-se]

Essa é a regra adotada pelos Tribunais Superiores a respeito do tema, sendo que, excepcionalmente, haverá algumas exceções, como, por exemplo, fora cabalmente demonstrada que não possui lesividade para a sociedade e também a quantidade de munição encontrada. Assim os julgados esclarecem:

"HABEAS CORPUS. PORTE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE ARMA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO QUE NÃO PODE LEVAR À PROTEÇÃO DEFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, tem entendido pela incidência do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei 10.826/03, afastando a tipicidade material da conduta quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal. 2. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ficar restrita a hipóteses excepcionais que demonstrem a inexpressividade da lesão, de forma que a incidência do mencionado princípio não pode levar ao esvaziamento do conteúdo jurídico do tipo penal em apreço - porte de arma, incorrendo em proteção

deficiente ao bem jurídico tutelado. 3. Não se mostra insignificante, embora em pequena quantidade, a apreensão de munições de uso restrito e de grosso calibre (1 de calibre 9mm, 2 de calibre 5.56mm, de uso restrito e utilizado para fuzis da plataforma AR; e 1 de calibre 7.62, também de uso restrito e utilizadas para fuzis da plataforma AK), portadas por indivíduo que tentava entrar no Fórum da cidade do Rio de Janeiro e, ainda, trazendo consigo diversas anotações atinentes ao tráfico de drogas. 4. Caso concreto que evidencia a efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado - a paz e a incolumidade pública. 5. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 473.334 RJ 2018/0265500-0, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, data de julgamento: 21/05/2019, T6 - Sexta turma, Data de publicação: DJe 30/05/2019)."

Assim, em raras exceções é possível a aplicação do princípio da insignificância no caso de posse de munição. O que não é o caso dos autos. A quantidade apreendida (12 munições) não pode ser considerada ínfima, quando se analisa o conjunto probatório. Deveras, as circunstâncias em que os artefatos foram encontrados - junto com grande quantidade de entorpecentes e vasto material para fracionamento e disseminação dos tóxicos - remontam para a grande lesividade da conduta.

Mesmo que não fora encontrada nenhuma arma de fogo para a utilização das munições, não é difícil concluir que tais artefatos auxiliam para a prática e disseminação do tráfico de drogas, devendo a conduta ser reprovada pelo ordenamento jurídico.

Mais uma vez, não se desconhece casos excepcionais em que a posse de munição, em pequena quantidade e em situações que não demonstrem lesividade a um bem jurídico tutelado seja considerada atípica. Ocorre que tal situação não se demonstra in casu. Como vimos, não se trata de apenas poucas munições que estavam guardadas a esmo, esquecida por vários anos em cantos intocáveis, ou que eram objeto de algum enfeite que fora presenteado por alguém. As condições fáticas demonstram o conluio criminoso em que esses materiais estavam envolvidos, o que torna inaplicável o princípio da insignificância no presente caso.

Noutro giro, em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, entendo que a prática do delito não ficou suficientemente comprovada.

Afinal, para a configuração do crime em questão, é necessário a demonstração da estabilidade e permanência do vínculo subjetivo, o que de fato, não restou devidamente configurado. Isso porque não se vislumbra vontade consciente e organizada para fins de traficância, elemento que caracteriza o crime.

Ademais, não restou devidamente comprovada a associação do réu a outras pessoas para o fim de traficância. Isso porque, os elementos que foram trazidos a este juízo não são suficientemente claros para se estabelecer tal instituto. A notícia de associação se dá quando, informalmente, o réu teria dito aos policiais militares no momento de sua prisão, que receberia uma quantia em dinheiro para fracionar os entorpecentes.

Ocorre que não há elementos que corroborem tal afirmação. As pessoas que supostamente estariam envolvidas na associação sequer foram identificadas. Não se tem notícia de que o réu estaria envolvido em algum tipo de organização, sendo que este é primário e como as testemunhas, policiais militares, disseram em juízo, o réu não era conhecido nos meios policiais. Ademais, não há denúncias anteriores, mesmo que anônimas, de que o réu estivesse envolvido em práticas delitivas.

Nesse tipo de crime é evidente que deve haver uma vontade consciente em se organizar para praticar o delito de tráfico de drogas, sendo que esse elemento deve estar devidamente comprovado nos autos. Não é raro nos delitos de associação o agente ter uma certa organização, com diversas hierarquias entre as funções, para a realização da prática do delito. Assim, na lição de Vicente Greco, in Tóxicos, prevenção-repressão,^{14ª} edição, atual. e ampl., São Paulo, Ed. Saraiva, 2011:

"Para haver crime autônomo de associação em matéria de entorpecentes é mister um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que determina a coautoria. É mister haja o dolo específico:

associar para traficar (...). Diante, pois, destas considerações o crime de associação (art. 35) como figura autônoma há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores. Jamais a simples coautoria ocasional, transitória, esporádica, eventual configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração." [grifou-se].

Nota-se que tais elementos caracterizadores para o crime de associação para o tráfico não se mostraram evidentes, sendo que, com dúvida razoável nesse particular, é imperiosa a absolvição do crime de associação ao tráfico, uma vez que a materialidade e autoria deve ser certa e indubitosa, o que não se mostra no presente caso.

Assim, diante de todo o exposto, é de rigor, evidenciados a materialidade e a autoria, a condenação do réu nos crimes de tráfico de drogas e porte de munição de uso permitido, bem como a absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira etapa, em análise em sua folha de antecedentes (fls. 36/38) verifico que o réu não ostenta antecedentes criminais. No mais, em atenção ao teor do artigo 59 do Código Penal, não se vislumbra outra circunstância judicial a ser reprovada. Anoto que, em atenção ao art. 42 da Lei nº 11.343/06, verifico que a natureza/quantidade de droga é reprovável. Contudo, tal elemento será analisado na terceira etapa, sendo que para evitar odioso bis in idem, deixo de valorá-lo na primeira etapa. Assim, não havendo circunstâncias judiciais a serem consideradas, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão para o delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e de 01 (um) ano de detenção para o delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incidem circunstâncias agravantes, mas incide a atenuante da menoridade relativa, uma vez o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (conforme demonstra fl. 25). Entretanto, na trilha da súmula nº 231 do STJ, deixo de atenuar a pena, uma vez que já fixada no mínimo legal, razão pela qual fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão para o delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e de 01 (um) ano de detenção para o delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03. Destaca-se o não reconhecimento da confissão espontânea, uma vez que o réu não admitiu a prática do delito, se limitando à alegação (que em nada restou comprovada nos autos) de que fora obrigado a guardar uma sacola, cujo conteúdo desconhecia, e que somente quando os policiais realizaram a busca em sua residência é que soube que ali havia entorpecentes. Ademais, verifica-se também a não aplicação da agravante relacionada pelo Ministério Público do artigo 61, inciso II, alínea j, dado que tal circunstância (calamidade pública) não guarda nexos causal com o caso, sendo que o réu não se aproveitou da situação de pandemia causada pelo COVID-19 para o cometimento do delito. Adota-se, pois, interpretação restritiva acerca da aplicação dessa agravante, sob pena de aplicá-la a todo e qualquer delito cometido em território nacional a partir de 16 de março de 2020. Em suma, não há que se falar em reconhecimento da agravante.

Por derradeiro, já no terceiro momento, constato a inexistência de causas de aumento e diminuição da pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão para o delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e de 01 (um) ano de detenção para o delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03. Nesse ponto, incabível é a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Embora o réu não ostente antecedentes criminais, a natureza e quantidade de drogas apreendida é reprovável, bem como os demais elementos fáticos – vasta quantidade de material de preparo/distribuição dos entorpecentes, além de munições encontradas com os entorpecentes. Nesse sentido: "(...) III - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,

vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. IV - Quanto ao punctum saliens, na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas e diversidade de entorpecentes apreendidos (865,8 g de maconha e 3,4 g de cocaína), e nas demais circunstâncias da apreensão e da prisão em flagrante do paciente, em decorrência de denúncia de sua genitora de que aquele guardava um tablete de maconha em sua residência) e a apreensão (uma parte do entorpecente encontrada na posse do réu em local conhecido pela venda de drogas e a outra parte encontrada em sua residência, juntamente com tesoura e faca com resquício de cocaína e dinheiro em notas miúdas), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que o paciente se dedicava às atividades criminosas (...) Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg noHC 568.062/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)."

Além disso, o réu fica condenado ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa referente ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 10 (dez) dias-multa referente o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03, cada qual no valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo ao tempo do fato, uma vez que não há elementos que comprovem a capacidade financeira do réu.

Portanto, procedendo-se finalmente ao somatório das penas (art. 69 do Código Penal), fica o réu condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e 01 (um) ano de detenção, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

De acordo com o art. 33, § 2º, alínea 'a', do CP, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda. Destaca-se que se trata de crime hediondo, sendo que o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser em regime mais gravoso, mormente diante das circunstâncias concretas do caso ora em julgamento, evidenciadas pela notória quantidade de entorpecentes e de munições apreendida com o ora sentenciado.

Considerando o quantum de pena aplicada, inviável a substituição da pena previsto no artigo 44 do Código Penal.

No mesmo sentido, também é inviável a benesse prevista no artigo 77 do Código Penal, sendo deixo de conceder o benefício da suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu LUCAS JOSÉ RODRIGUES à pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, de 05 (cinco) anos de reclusão, e 01 (um) ano de detenção, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, respectivamente, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa; e ABSOLVER o réu LUCAS JOSÉ RODRIGUES da prática do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, o que faço com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP.

CONDENO o réu ao pagamento das custas, nos termos do art. 804 do CPP, observada a eventual gratuidade.

NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que subsistem os fundamentos da custódia cautelar, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade em concreto do crime e a sua hediondez, visto a grande quantidade de droga encontrada e vasto material para a sua disseminação, o que remonta à gravidade e o perigo para a comunidade a prática de referido crime, fomentando ainda mais para mais atitudes de traficância.

Assim, MANTENHO, portanto, a prisão preventiva do réu, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Anote-se a revisão da prisão no sistema SAJ, notadamente para futura reapreciação, devendo a Serventia observar o disposto no Comunicado CG nº 78/2020.

RECOMENDE-SE o réu onde estiver preso.

Após o trânsito em julgado:

I. expeça-se certidão de honorários ao patrono dativo;

II. lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

III. expeça-se a competente guia de execução;

IV. expeça-se Ofício ao E. TRE; e

V. expeça-se Ofício ao IIRGD (art. 809, CPP).

Oportunamente, ARQUIVEM-SE.

P.R.I.

Marília, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA